

1523131-61.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/09/2022

... E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523131-61.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523131-61.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO JEFFERSON ALVES DE MELO e outros

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ROBERTO JEFFERSON ALVES DE MELO, LUCAS SILVA MOURA e NICOLAS DA CRUZ SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 24 de setembro de 2019, por volta das 02h45min, na Avenida Patente, nº 840, Sacomã, São Paulo/SP, previamente acertados e conluiados entre si, tentaram subtrair, para proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, pertencentes à empresa RAIA DROGASIL, consistentes em inúmeros produtos e medicamentos do estabelecimento, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 150/152). Os acusados foram presos em flagrante (fls. 01), sendo a custódia convertida em preventiva (fls. 87/91). Os acusados ROBERTO JEFFERSON ALVES DE MELO e LUCAS SILVA MOURA foram soltos com imposição de medidas cautelares (fls. 171/173, 183/185 e 186/188).

A denúncia foi recebida (fls.171/173), os réus foram citados (fls. 199 - Roberto, 200- Lucas e 223- Nicolas).

O réu NICOLAS DA CRUZ SANTOS ofereceu resposta escrita à acusação com pedido de liberdade provisória (fls. 231/235) a qual foi indeferida pela decisão de fls. 243/244, com confirmação da decisão de fls. 265/267 e 291. A fls. 315/316 foi

concedida liberdade provisória a NICOLAS DA CRUZ SANTOS com imposição de medidas cautelares (fls. 330/333).

O réu LUCAS SILVA MOURA apresentou resposta à acusação (fls. 350).

O réu ROBERTO JEFFERSON ALVES DE MELO apresentou resposta à acusação (fls. 355/356) e teve formulado em seu benefício Acordo de Não Persecução Penal (fls. 361) o qual, na audiência de instrução (fls. 430/432), foi estendido para o acusado LUCAS SILVA MOURA, acordos estes homologados em audiência.

A seguir, ratificado o recebimento da denúncia em relação ao réu NICOLAS DA CRUZ SANTOS, durante a instrução, foram ouvidas a representante legal da empresa vítima e uma testemunha, bem como interrogados o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A defesa requereu seja considerada a atenuante da confissão na dosimetria da pena e, sobre o regime inicial, requereu se proceda a detração, tendo em consideração que o acusado foi mantido em prisão durante cerca de 14 meses, isso com fundamento no artigo. 387, §2º do Código de Processo Penal e em vista da Súmula 716 STF, para que aplique regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente em relação ao réu NICOLAS DA CRUZ SANTOS.

A materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelo(a)s Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Termos de Depoimentos (fls. 18 e 19), Termos de Declarações (fl. 20), Termos de Interrogatório (fl. 21, 22 e 115/116), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15), Relatório Final (fls.117/118), Laudo Pericial do Local dos Fatos (fls. 153/156) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Ouvida Dalvinha Cardoso Sobrinho, representante da empresa vítima, esclareceu que os fatos aconteceram no decorrer da noite. A farmácia estava fechada e me ligaram poque havia caído a conexão do alarme da loja. Alguém do serviço de segurança já tinha chegado antes de mim e a policia prendeu as pessoas que entraram na farmácia. Viu os produtos que eles levaram e compareceu à delegacia para para os receber de volta. Eles levantaram a porta de aço e quebraram o vidro para entrar no local. Para eles entrarem ele tiveram que quebrar o vidro.

O policial militar Edson Monstesino, ouvido como testemunha, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo parado na frente da drogaria. Em razão do horário, acharam estranho e efetuaram a abordagem. Quando estava abordando o condutor do veículo, saíram de dentro da drogaria mais duas pessoas com uma trouxa com produtos da farmácia. Dentro do veículo tinha mais produtos que já haviam sido subtraídos da drogaria. Não conhecia os acusados antes dos fatos. Uma funcionária da drogaria compareceu no local e reconheceu os produtos. Eles confessaram. Havia arrombamento da janela.

O teor de seu depoimento confirmou o quanto ele e seu companheiro de farda já haviam relatado na delegacia (fls. 18 e 19).

O réu NICOLAS confessou a prática delitiva na delegacia e em juízo.

Em juízo, ainda, disse que está arrependido do que fez. Pediu desculpas e uma oportunidade.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

A confissão do réu, confirmou a prática delitiva e corroborou as declarações da vítima e o depoimento da testemunha, colhidas sob o crivo do contraditório.

É de asseverar, ainda, que o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas.

Ainda, as declarações da representante da vítima e o depoimento da testemunha mantiveram os aspectos nucleares de forma congruente e concatenada quanto às narrativas apresentadas em solo policial (fls. 20). Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar

a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)".

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

As qualificadoras descritas na denúncia também vieram devidamente comprovadas nos autos pelas provas colhidas, notadamente pelo laudo do local dos fatos de fls.153/156.

O teor do exame e as fotografias são contundentes em apontar o rompimento de obstáculo pela retirada dos bens do interior da drogaria, tanto em relação ao vidro que foi quebrado tanto em relação à porta de ação que contava com indícios de arrombamento.

Nesse passo, não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4º, do artigo 155, do Código Penal.

Certamente o acusado não atuou "contra a própria coisa", mas sim a fim de subtrair os elementos contidos no interior da drogaria, valendo-se, para tanto, do rompimento de obstáculo mediante a quebra do vidro e a tentativa de arrombamento da porta de aço.

Verifica-se também que o furto se deu durante o período noturno, fato este que foi devidamente descrito na denúncia.

Nesse aspecto, em que pese já ter me manifestado em sentido diverso, melhor revendo a questão, não há falar em afastamento do repouso noturno apenas em razão da posição topográfica do § 1º, do artigo 155, do Código Penal.

Compulsando recentes julgados dos tribunais superiores, verifica-se a necessidade de novas reflexões sobre a questão topográfica nos tipos penais e seus reflexos na dosimetria da pena.

De fato, não se desconhece que há decisões baseadas na argumentação de que, por uma questão topográfica, não caberia aplicar preceito antecedente ao subsequente e que a maior gravidade da figura qualificada e da pena a ela cominada já abrangeria as hipóteses descritas nas majorantes. Com o tempo, contudo, começou-se a perceber que essa não era a melhor interpretação e que o legislador brasileiro não se ateve a tal critério (o topográfico), quando da elaboração das leis. Tal entendimento começou, então, a mudar, notadamente no que diz respeito aos crimes de homicídio e furto, nos quais já se pacificou que a simples posição topográfica dos parágrafos em nada impediria a figura do crime "qualificado- privilegiado", ou mesmo o reconhecimento da figura do "repouso noturno" aos delitos de furtos qualificados.

A doutrina, então, começou a analisar tais decisões e passou-se a considerar, nestes casos, que "a posição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da pena. Outras considerações, para não aplicar o aumento do § 1.º às formas qualificadas (§ 4.º ou § 5.º), constituem pura política criminal, visando à menor apenação ao acusado, embora distante da técnica de individualização da pena. Nesse sentido: "Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples, sendo incabível no caso do delito qualificado (Precedente)" (STJ - REsp 940.245-RS, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, 13.12.2007, v.u.); HC 10.240-RS, 6.ª T., rel. Fernando Gonçalves, 21.10.1999, v.u., DJ 14.02.2000, p. 79. Em seu voto no HC 306.450/SP, a ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou: Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2.º do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1.º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4.º do dispositivo.

Ademais, cumpre salientar que o § 1.º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico.

Por outro lado, registra-se que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma desta Corte segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento, quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EResp 842.425/RS,

no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2.º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2º), também não se considera tal ordem para imposição da causa de aumento (§ 1º).

E, assim sendo, tendo em vista que o furto em tela é qualificado pelo rompimento de obstáculo, não há qualquer óbice para aplicação da causa de aumento de pena (art.155, § 1º, do Código Penal), devendo, portanto, ser mantida.

Cumprir destacar julgado que fixa justamente essa orientação ao enfrentar hipótese análoga: PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. BEM AVALIADO EM R\$ 300,00. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA PENA-BASE. SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Na espécie, o Tribunal aquo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus [...] 5. Ordem denegada" (ProcessoHC 424098/SC - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,j. 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

No mesmo sentido e, corroborando o entendimento ora esposado, o Supremo Tribunal Federal no HC 130952/MG, assim já se pronunciou:"HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I, C/C O ART. 14, II).CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO(CP, ART. 155, § 1º) NAS FORMAS QUALIFICADAS DO CRIME DE FURTO (CP, ART. 155, § 4º). ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE CONTRADIÇÃO LÓGICA QUE POSSA OBSTAR A CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DOS DOIS INSTITUTOS QUANDO PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO FÁTICA. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto,que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico)teria sido feita com intenção de não a submeter às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno(CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada". (STF -HC 130952/MG, Relator Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 13/12/2016 - Info851).

No mais, tendo o acusado confessado e sido surpreendido enquanto retirava os bens de dentro da farmácia, permanece bem delineada a tentativa de subtração.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena

NICOLAS DA CRUZ SANTOS, tem 27 anos de idade. É solteiro e não tem filhos. Estudou até o segundo grau completo. É auxiliar de técnico de telecomunicação. Trabalhava com clientes de família. Afirmou ter renda mensal de aproximadamente R\$ 1.200,00 a R\$ 1.800,00. Mora em casa alugada, com sua mãe. Já foi processado por roubo. Foi condenado. Cumpriu a pena.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que estão bem delineadas 02 (duas) qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e VI, do Código Penal, sendo que, uma delas deve ser utilizada como

circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (STJ - HC

483.025/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/3/2019, DJe 9/4/2019).

Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/5 (um quinto), perfazendo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de NICOLAS, o qual assumiu a prática delitativa em juízo. Ainda, sobressai a dupla reincidência do acusado pela prática de crimes patrimoniais. Ainda, anoto que o réu ostenta maus antecedentes pela prática de crimes patrimoniais (0033892-51.2017.8.26.0050 e 0092745-92.2013.8.26.0050).

Nesse passo, de rigor a compensação da atenuante genérica com a reincidência de NICOLAS devendo prevalecer, no caso, a incidência de 01 (uma) das condenações anteriores como fator de elevação das penas: "Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente [...]" (STJ - AgRg no HC 462544/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, p.

30/03/2021). Assim, ante a consideração da reincidência específica prevalecente, elevo as sanções na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira etapa, considerando a prática do delito durante o repouso noturno, por força de previsão legal a pena deve ser aumentada no coeficiente de 1/3 (um terço), chegando-se a 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa. De outro lado, levando-se em conta a tentativa, sopesado o iter criminis percorrido - o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado quase todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela intervenção dos policiais quando ainda precisava colocar os bens no veículo e deixar o local - diminuo a pena na fração de 2/5 (dois quintos), resultando, em definitivo, em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar NICOLAS DA CRUZ SANTOS como incurso no artigo 155, § 1º; e § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários. A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Tendo permanecido solto no decorrer do processo e não sobrevivendo notícia que determinasse sua prisão cautelar, defiro o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia definitiva.

Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Comunique-se à vítima, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA